

<제2편 소송의 주체.제4장 당사자.제1절 당사자의 개관>

I. 당사자 일반론

1. 당사자론의 논점

- 통상적으로 소장을 작성하는 자는 실체법상 법률관계의 권리자를 원고로, 의무자를 피고로 적게 된다. 따라서 권리자가 원고이고, 의무자가 피고라고 속단하기 쉬우나, 이렇게 당사자를 정의하면 문제점이 발생한다. 우선 현실의 소송절차에서 원고가 모두 승소하는 것은 아니다. 소송결과 패소한 자는 실체법상 법률관계에서 권리자가 아닌 것으로 판명된 자이다. 그렇다고 해서 패소자를 원고가 아니라고는 하기 어렵다. 이 문제점은 자기가 실체법상 법률관계의 권리자라고 주장하는 자를 원고, 이러한 원고에 의하여 의무자라고 주장되는 자를 피고라고 보게 되면 해결되나, 이러한 방법만으로는 설명하기 어려운 부분이 존재한다. 예를 들어 파산절차의 개시로 파산관재인이 선임된 경우와 같이 어떤 재산의 권리자와 관리처분권자가 분리되어 각기 다른 사람에게 귀속되는 경우, 법률이 정하는 바에 따라 조금씩 차이가 있기는 하나, 파산관재인이 선임된 경우에는 파산관재인이 원고가 된다.

2. 당사자의 개념

- 전술한 경우까지 모두 포섭할 수 있도록 당사자의 개념을 정의하면, 당사자는 자기의 이름으로 판결을 요구하는 사람과 그 사람에 의하여 상대방으로 지목된 사람이라고 할 수 있다. 이러한 당사자의 개념을 형식적 당사자 개념이라고 부른다.

II. 당사자확정

1. 당사자확정의 의의

- 당사자확정이란 현실적으로 전개되고 있는 소송절차에서 누가 원고이고 누가 피고인가를 결정하는 작업을 말한다. 소장에 기재된 표시와 실제 소송을 수행하는 자가 일치하지 않거나, 사망자를 상대로 소를 제기하는 등 당사자의 정체성에 의문이 있는 경우에 누구를 당사자로 보아 절차를 진행할 것인지가 문제된다. 이는 당사자능력이나 당사자적격을 판단하기 위한 선행 작업이다.

2. 당사자확정의 기준

(1) 학설

- 당사자를 어떠한 기준으로 확정할 것인가에 대하여 세 가지 견해가 대립한다. 첫째, 의사설은 소를 제기하는 원고나 법원의 주관적 의사를 기준으로 당사자를 결정해야 한다는 견해이다. 둘째, 표시설은 소장의 당사자란의 기재 및 청구취지 등 외관상 나타난 표시를 기준으로 결정해야 한다는 견해이다. 셋째, 규범설(실질적 표시설)은 소장의 전체적인 기재와 소송의 전 과정을 통하여 합리적인 제3자가 객관적으로 판단하였을 때 누구를 당사자로 보고 있는가를 기준으로 결정해야 한다는 견해로, 현대 소송법의 통설적 입장이다.

(2) 판례

- 판례는 원칙적으로 규범설의 입장을 취하고 있다. 소장에 기재된 표시뿐만 아니라 청구원인 등 전체적인 내용을 종합하여 객관적으로 당사자를 확정하여야 한다고 본다. 특히, 당사자 표시가 잘못되었다고도 실질적으로 누구를 가리키는지 명확하다면 표시정정을 통해 바로잡을 수 있다고 판시하여, 절차의 형식적 기재보다는 실질적 관련성을 중시한다.

(3) 검토

- 의사설은 주관적 요소로 인해 법적 안정성을 해칠 수 있고, 표시설은 명확하나 지나치게 형식에 치우칠 우려가 있다. 따라서 소장의 전체적인 기재를 바탕으로 객관적으로 당사자를 확정하는 규범설이 타당하다.

3. 당사자확정 후 당사자적격 판단과 흠결 시 보정방법

(1) 당사자적격 판단 및 보정

- 당사자가 확정된 후에는 그 자가 당사자능력이 있는지, 해당 사건의 본안판결을 받기에 적합한 자격인 당사자적격이 있는지를 판단한다. 만약, 확정된 당사자에게 이러한 자격이 흠결되었다면 소송요건 불비로 소가 각하될 수 있다.

(2) 보정조치

- 법원은 소송요건의 흠결을 발견한 경우 즉시 각하하기보다 당사자에게 보정할 기회를 부여하여야 한다. 이는 국민의 재판받을 권리를 보호하고 소송 경제를 도모하기 위함이다.

(3) 보정방법

- 당사자 능력이 없는 자를 있는 자로 바꾸거나, 적격이 없는 자를 있는 자로 교체하는 방식이 사용된다. 다만, 이는 당사자의 동일성을 해치지 않는 범위 내에서의 당사자표시정정이나 법률이 정한 당사자변경(피고경정 등)의 절차를 통해 이루어져야 한다.

III. 당사자표시정정

1. 의의

- 당사자표시정정이란 당사자의 동일성을 유지하면서 소장에 기재된 잘못된 명칭이나 주소 등을 바르게 고치는 것을 말한다. 이는 새로운 당사자를 추가하거나 교체하는 당사자변경과는 구별된다.

2. 요건

(1) 동일성 인정

- 당사자의 동일성이 인정되어야 한다. 단순히 명칭을 오기하였거나 법인의 종류를 잘못 기재한 경우 등 실질적으로 같은 사람을 지칭하고 있음이 객관적으로 인정되어야 한다.

(2) 방어권 준수

- 정정으로 인해 상대방의 방어권이 침해되지 않아야 한다.

3. 절차

- 당사자는 신청서를 제출하여 표시정정을 구할 수 있으며, 법원은 동일성이 인정된다면 이를 허가하는 결정을 내린다. 실무상으로는 변론기일에서 구술로 신청하고 조서에 기재하는 방식도 널리 사용된다.

4. 효력

- 표시정정이 이루어지면 소급하여 처음부터 정정된 당사자 사이에 소송이 계속된 것으로 본다. 따라서 시효중단이나 기간 준수의 효력은 소 제기 시를 기준으로 유지된다.

IV. 성명모용소송

1. 의의

- 성명모용소송이란 원고 또는 피고가 타인의 성명을 무단으로 사용하여 소송을 수행하는 것을 의미한다. 모용자가 피모용자인 것처럼 행세하여 법원을 기망하는 행위이다.

2. 당사자의 확정

- 규범설에 의할 때, 소송을 실제 수행하고 있는 모용자가 당사자로 확정된다. 이름은 피모용자의 것이나 실질적으로 소송의 주체가 되는 자는 모용자이기 때문이다.

3. 발견 시 법원의 조치

- 법원이 소송 중에 모용 사실을 발견하면, 당사자 표시가 실제 소송 수행자와 일치하지 않으므로 당사자표시정정을 명하여야 한다. 만약, 원고가 모용자임이 밝혀지고 이를 정정하지 않는다면 소를 각하하며, 피고가 모용된 경우에는 모용자를 절차에서 배제하고 실제 피고를 참여시켜야 한다.

4. 간과판결의 효력 및 피모용자의 구제책

- 성명모용을 간과하고 판결이 내려진 경우, 판결의 효력은 실제 당사자인 모용자에게 미친다. 그러나 판결서에 이름이 기재된 피모용자에게 외관상 효력이 미칠 위험이 있으므로, 피모용자는 대리권 흠결을 이유로 상소를 제기하거나 판결 확정 후 재심을 통해 자신의 권리를 구제받을 수 있다. 판례는 피모용자가 판결의 효력을 받지 않음을 명확히 하고 있다.

5. 송달과정에서 피고모용

- 피고의 성명이 모용되어 판결 정본이 피모용자에게 송달된 경우, 피모용자는 자신에게 판결의 효력이 없음을 주장하는 집행에 관한이의 등을 제기할 수 있다.

V. 사자상대소송

1. 제소 전에 사망한 경우

- 원고가 이미 사망한 자를 피고로 기재하여 소를 제기한 경우이다. 이때 당사자확정 기준에 따라 사자(死者)가 당사자로 확정되나, 사자는 당사자능력이 없으므로 원칙적으로 소는 부적법하다. 다만, 원고가 피고의 사망 사실을 모르고 제소한 경우 실질적 피고인 상속인으로 당사자표시정정을 하는 것이 허용된다는 것이 판례의 태도이다.

2. 소제기 후 소장부분 송달 전에 피고가 사망한 경우

- 이 시기에는 아직 소송계속이 발생하기 전이므로, 원고는 상속인으로 당사자표시정정을 하여 절차를 유지할 수 있다. 만약, 이를 간과하고 사자에게 송달되어 판결이 났다면 그 판결은 당연무효이다.

3. 소송대리인에게 소송위임 후 제소 전 사망한 경우의 법률관계

- 판례에 의하면 소송대리인에게 소송을 위임한 후 소 제기 전에 당사자가 사망하더라도 소송대리권은 소멸하지 않는다.(민소법 제95조) 따라서 이 경우의 소 제기는 유효하며, 사망한 자의 상속인이 소송을 승계하게 된다.

4. 소송계속 후 변론종결 전에 사망한 경우[민소법 제233조]

- 소송 도중 당사자가 사망하면 소송절차는 당연히 중단된다. 이때 상속인 등이 소송절차를 승계하여야 한다. 법원이 사망 사실을 모르고 중단 절차 없이 내린 판결은 대리권 흠결과 유사한 하자가 있는 판결로서 상소나 재심의 대상이 된다.

5. 변론종결 뒤에 사망한 경우

- 변론이 종결된 후에는 당사자의 참여가 필요 없으므로 소송절차는 중단되지 않으며, 법원은 사망한 자를 그대로 당사자로 하여 판결을 선고할 수 있다. 이 판결의 효력은 상속인에게 미친다.

VI. 법인격부인

1. 법인격부인의 법리

- 법인격부인이란 특정한 사안에서 법인의 독립된 인격성을 부정하고 그 배후에 있는 개인이나 다른 회사에 책임을 묻는 이론이다. 법인이 형해화되었거나 채무 면탈 등 불법적인 목적으로 남용되는 경우에 적용된다.

2. 법인격이 부인되는 법인에 대한 소제기가 적법한지 여부

- 법인격부인의 법리가 적용되더라도 법인의 존재 자체가 소멸하는 것은 아니다. 따라서 해당 법인을 상대로 소를 제기하는 것 자체는 당사자능력 면에서 적법하다. 다만, 실질적인 책임을 배후자에게 묻기 위한 절차가 추가로 필요할 뿐이다.

3. 발견 시 채권자의 조치

- 채권자는 법인뿐만 아니라 그 배후자를 공동피고로 하여 소를 제기하거나, 이미 법인에 대한 판결을 얻은 경우 배후자에게 별도의 소를 제기하여 집행권원을 확보해야 한다. 판례는 원칙적으로 법인에 대한 판결의 기판력이나 집행력이 당연히 배후자에게 미치지 않는다고 보므로, 별도의 제소가 필요함을 유의해야 한다.

VI. 결론

- 당사자의 확정 은 민사소송의 인적 범위를 결정하는 첫 단추로서 공정한 재판을 위한 필수적 전제이다. 규범설과 판례의 태도에 따라 실질적인 당사자를 확정하고, 표시상의 오류는 당사자표시정정을 통해 유연하게 해결함으로써 소송 경제를 도모할 수 있다. 또한 성명모용이나 사자상대소송과 같은 특수한 경우에도 당사자 보호와 절차의 안정을 동시에 고려하는 법리적 해석이 요구된다. 법원은 당사자의 정체성에 관한 의문을 소홀히 다루지 않으므로써, 판결의 효력이 엉뚱한 자에게 미치는 부당한 결과를 사전에 방지하여야 할 것이다.